

《【문제2】 건축사업자 甲은 X시장으로부터 건축허가를 받아 건물의 신축공사를 진행하던 중 건축법령상의 의무위반을 이유로 X시장으로부터 공사중지 명령을 받았다. 甲은 해당 법령의무위반을 하지 않았다고 판단하고, 공사중지명령처분의 위법하다고 주장하며 공사중지명령처분의 무효확인소송을 제기하였다. 법원은 사건의 심리결과 해당 처분에 `중대한` 위법이 있음이 인정되지만 `명백한` 위법은 아닌 것으로 판단하였다. 법원은 어떠한 판단을 내려야 하는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 공사중지명령의 무효확인을 구하는 소송에서 심리 결과 취소사유만 인정되는 경우 법원의 판단

I. 문제의 제기

- 사안에서 건축사업자 甲이 건축법령상 의무위반을 이유로 받은 공사중지명령처분에 대하여 무효확인소송을 제기하였고, 법원은 해당 처분에 중대한 위법은 있으나 명백한 위법은 없다고 판단하는 상황이다. 쟁점으로 <행정처분의 무효확인을 구하기 위한 중대성 및 명백성 요건 중 명백성 요건이 충족되지 않은 경우 법원이 어떠한 판단을 하여야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인소송에서 처분의 무효 판단 기준과 중대·명백성 요건의 충족 여부에 따른 법원의 판단에 대해 설명한다.

II. 무효확인소송과 취소사유인 하자의 관계에 관한 법리

1. 하자의 정도와 처분의 효력

(1) 당연무효와 취소사유의 구별 기준 (중대·명백설)

- 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 처분에 존재하는 하자가 헌법이나 법률의 중요 규정을 위반한 것으로서 객관적으로 중대할 뿐만 아니라, 외관상 일견하여 누구나 명백하게 인식할 수 있어야 한다.

(2) 명백성 결여와 취소사유의 성격

- 하자가 객관적으로 중대하다고 하더라도 외관상 명백하지 않은 경우에는 처분은 당연무효가 되지 않고 단순한 취소사유에 그친다. 이러한 단순 취소사유인 처분은 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지는 공정력(구성요건적 효력)에 의하여 원칙적으로 유효한 처분으로 취급된다.

2. 무효확인소송에서 취소판결 선고의 가부

(1) 취소 청구 포함의 법리 (소의 포함 관계)

- 원고가 처분의 무효확인을 구하는 소송을 제기한 경우, 특별한 사정이 없는 한 처분의 무효확인을 구하는 청구 취지 중에는 처분이 당연무효가 아니라면 취소라도 해달라는 취소를 구하는 취지가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석하는 것이 합리적이다.

(2) 취소소송 소송요건 구비 여부에 따른 사법적 처리

- “대법원 판례”에 따르면 처분의 당연무효를 구하는 소에 취소소송의 소송요건(특히 제소기간 및 행정심판 전치주의 등)이 모두 구비되어 있다면, 법원은 무효 청구를 기각하는 대신 처분을 취소하는 취소판결을 내려야 한다. 반면, 제소기간 도과 등 취소소송의 소송요건을 갖추지 못하였다면 법원은 예외적으로 취소판결을 내릴 수 없으므로 무효 청구를 물리치는 기각판결을 내려야 한다.

III. 사안의 적용

1. 공사중지명령 하자의 법적 성격

(1) 하자의 중대성 인정과 명백성 흠결

- 사안의 공사중지명령은 심리 결과 중대한 위법은 존재하지만 명백한 위법은 존재하지 않는 상태이다. 따라서 하자의 중대·명백설에 의할 때, X시장의 처분은 당연무효에 해당하지 않는다.

(2) 단순 취소사유로의 확정

- 따라서 사안의 공사중지명령에 존재하는 하자는 단순 취소사유에 불과하므로, 처분 자체는 공정력을 가져 취소판결로 제거되기 전까지는 유효한 처분으로 유지된다.

2. 법원의 구체적 판결 방향

(1) 취소소송의 소송요건을 충족한 경우

- 만약 甲이 무효확인소송을 제기할 당시에 취소소송의 제소기간(처분이 있음을 안 날부터 90일, 처분이 있는 날부터 1년 이내)을 적법하게 준수하였고 기타 필요적 행정심판전치주의 등의 요건을 충족하였다면, 법원은 소의 포함 관계를 인정하여 공사중지명령을 취소하는 취소판결을 선고하여야 한다.

(2) 취소소송의 소송요건을 결여한 경우

- 만약 甲이 소를 제기한 시점이 이미 처분이 있음을 안 날부터 90일을 도과하는 등 취소소송의 제소요건을 흠결한 상태였다면 법원은 하자가 단순 취소사유에 불과하더라도 취소판결을 내릴 수 없다. 또한 처분이 당연무효도 아니므로 무효확인 청구의 이유가 없어 법원은 甲의 청구를 물리치는 기각판결을 선고하여야 한다.

IV. 결론

- X시장의 공사중지명령은 중대하나 명백하지 않은 하자가 존재하므로 당연무효가 아닌 단순 취소사유에 해당한다. 무효확인소송에는 특별한 사정이 없는 한 취소소송의 청구가 포함되어 있으므로, 수소법원은 소송요건의 구비 여부를 개별적·독립적으로 심사하여야 한다. 결론적으로 수소법원은 당해 무효확인소송이 취소소송의 제소기간 등 소송요건을 갖추었을 때에는 공사중지명령을 취소하는 취소판결을 선고하여야 하고, 만약 취소소송의 소송요건을 흠결하였을 때에는 당연무효가 인정되지 않으므로 기각판결을 선고하여야 한다.